

正当防衛に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選りなさい。

1. 当然又はほとんど確実に侵害が予期された場合において、単に予期された侵害を避けなかったにとどまらず、その機会を利用して積極的に相手方に対し加害行為をする意思で暴行に及んだときは、その暴行行為については、正当防衛が成立する余地はない。
2. いわゆるけんか闘争において相手方に対してした暴行行為については、正当防衛が成立する余地はない。
3. 手拳で殴る素振りをしながら「お前殴られたいのか。」と言って近付いてきた相手方を、殺傷能力のある刃物を構えて脅した場合、その脅迫行為については、正当防衛が成立する余地はない。
4. 自己に対しナイフを示して脅している相手方に対し専ら攻撃の意思で暴行に及んだ場合、その暴行行為については、正当防衛が成立する余地はない。
5. 財産的権利を防衛するために相手方の身体に暴行を加えて傷害を負わせた場合、その暴行行為については、正当防衛が成立する余地はない。

No85	正当防衛	正答率
共通R 1-15	正解 1、4 (順不同)	83%

1 正しい

最決昭 52.7.21 (百選 I [第7版] 23 事件) は、防衛行為者に積極的加害意思 (単に予期された侵害を避けなかったというにとどまらず、その機会を利用し積極的に相手方に対して加害行為をする意思) があった事案において、「当然又はほとんど確実に侵害が予期されたとしても、そのことからただちに侵害の急迫性が失われるわけではないと解する……しかし、……単に予期された侵害を避けなかつたというにとどまらず、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは、もはや侵害の急迫性の要件を充たさない」としている。判例に賛成する学説は、理由として、侵害を確実に予期しながら積極的加害意思をもって侵害に臨むような場合は、正当防衛状況を利用した単なる加害行為であって、公的機関に救助・救済を求める余裕があり、自力救済の禁止の例外を認めなければならないような緊急状態は存在しないということを挙げている。

2 誤っている

本記述は、喧嘩闘争において、正当防衛が成立する余地はないとしている点で、誤っている。最判昭 32.1.22 は、喧嘩闘争において正当防衛が成立するかが問題となった事案において、正当防衛の成立する余地を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、喧嘩においても、闘争の全般からみて社会的相当性を逸脱しない場合がありうるということを挙げている。

3 誤っている

本記述は、正当防衛が成立する余地はないとしている点で、誤っている。最判平元.11.13 (百選 I 25 事件) は、正当防衛の成立を認めている。判例に賛成する学説は、理由として、武器対等の原則は、違法判断における基準であるから、形式的に適用されるべき性質のものでなく、事例に応じて実質的に判断されるべき性質のものであるということを挙げている。

4 正しい

最判昭 50.11.28 (百選 I 24 事件) は、「防衛に名を借りて侵害者に対し積極的に攻撃を加える行為は、防衛の意思を欠く結果、正当防衛のための行為と認めることはできない」として、専ら攻撃の意思で反撃行為を行った場合、正当防衛の成立を否定する。判例に賛成する学説は、理由として、多少なりとも防衛の動機に基づく行為であれば防衛行為としての性格を失わないが、専ら攻撃の動機・意思で行った行為は、もはや防衛行為とはいえず、単なる加害行為となるということを挙げる。

5 誤っている

本記述は、財産的権利を防衛するために相手方の身体に暴行を加えて傷害を負わせた場合、正当防衛が成立する余地はないとしている点で、誤っている。最判平 21.7.16 は、正当防衛の成立を認めている。判例に賛成する学説は、理由として、防衛行為の相当性判断に際して、法益侵害と保全法益の権衡を問題とする場合、法益の種類のみならず、その法益の危殆化の程度、方法、攻撃者と防衛者の年齢差、体格差等を具体的状況に照らして実質的に判断すべきであるということを挙げている。

以上により、正しい記述は 1 と 4 であり、したがって、正解は肢 1 と肢 4 (順不同) となる。